

1502221-64.2021.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI
Comarca: Francisco Morato
Foro: Foro de Francisco Morato
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 24/04/2022
... Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Francisco Morato
Foro de Francisco Morato
2ª Vara
Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502221-64.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502221-64.2021.8.26.0544
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253447/2021 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 20300286 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2999/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2253447 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO
Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA
Réu:
PHILLIP FERNANDES BARBOSA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

PHILLIP FERNANDES BARBOSA (qualificado às fls. 18/21), está sendo processado por infração ao artigo 33, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal, porque, segundo narra a inicial acusatória, no 16 de setembro de 2021, por volta de 13h, em ocasião de calamidade pública, à Rua Joaquim Bazílio, altura do numeral 126, Jardim Vassouras I, nesta cidade e comarca de Francisco Morato/SP, nas imediações de estabelecimento de ensino, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vendia e trazia consigo, dentro de sacola plástica de cor preta: I) 28 (vinte e

oito) porções da droga conhecida como "maconha", com massa bruta total de aproximadamente 67g (sessenta e sete gramas); II) 92 (noventa e duas) porções da droga conhecida como "cocaína", com massa bruta total de aproximadamente 94g (noventa e quatro gramas); III) 43 (quarenta e três) porções da droga conhecida como "crack", com massa bruta total de aproximadamente 11g (onze gramas); IV) 03 (três) frascos de substância conhecida como "Lança-perfume", com volume bruto total de aproximadamente 80ml (oitenta mililitros).

Às fls. 54/56 foi convertido o flagrante em prisão preventiva do acusado.

A denúncia foi recebida (fls. 87/88).

Às fls. 107/108 foi designada audiência virtual de instrução e julgamento.

O denunciado foi citado e intimado (fls. 105/106) e apresentou Defesa Prévia (fls. 119/121).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 126/131), foi ratificado o recebimento da denúncia, o réu foi interrogado, bem como foi ouvida uma testemunha de acusação em comum com a defesa, havendo desistência da inquirição da testemunha William Santos, em razão de sua ausência.

O Ministério Público, em alegações finais, pediu a parcial procedência da ação. Quanto à dosimetria da pena, pleiteou que seja fixada a pena no mínimo legal e que na terceira fase não seja aplicado o redutor, diante da grande quantidade de entorpecente em poder do acusado, bem como que o acusado ficou preso pelo mesmo delito em data recente. Afirma que não presente a agravante da calamidade pública pois não relacionado ao tráfico de drogas, bem como não presente a agravante pelo local ser próximo à escola, pois não demonstrado se o acusado estava nas imediações do estabelecimento de ensino (fls. 126/127).

A Defesa apresentou alegações finais, pleiteando a absolvição do réu no caso em questão pela ausência de prova de autoria. Pede a desclassificação para usuário de drogas, artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação pede aplicação do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 126/127).

Documentos juntados: auto de exibição/apreensão da droga e dinheiro (fls. 11); laudo de constatação da droga (fls. 13/18); croqui do local dos fatos (fls. 72/73); laudo pericial químico toxicológico (fls. 81/83 e fls. 84/85); guia de depósito judicial (fls. 74/75); folha de antecedentes (fls. 99/101); certidão de distribuição criminal (fls. 102/103).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo, bem assim, laudo de constatação preliminar da droga e laudo de exame de substâncias psicoativas, auto de apreensão da droga/dinheiro e guia de depósito de dinheiro apreendido.

O réu foi interrogado na fase policial e fez uso de seu direito de permanecer calado. No interrogatório judicial, negou os fatos descritos na denúncia, relatando que é usuário de drogas e estava no local dos fatos para comprar maconha, que no momento que os policiais apareceram não teve como correr, pois tem problemas no joelho. Aduz que não estava com as drogas e os que estavam conseguiram escapar, mas como o interrogado não conseguiu correr, foi abordado e que havia consigo a quantia de R\$ 18,00. Momento em que os policiais acharam a droga e o interrogado disse que não era sua, mas os agentes disseram que ele estava no lugar errado, na hora errada. Relata que não conhecia os policiais. Declarou que ia comprar apenas uma porção de maconha no valor R\$ 5,00. Que não sabe a qualificação do verdadeiro traficante (fls. 130/131).

Por outro lado, a testemunha de acusação WILLIAM SANTOS DUARTE relatou na fase policial que: durante o serviço de patrulhamento por este município, ao passarem pela Rua Joaquim Basílio, local conhecido como ponto de venda de drogas avistaram 05 rapazes, os quais ao perceberem a presença policial empreenderam fuga, por uma ponte de madeira. O último, ao ver que não conseguiria fugir, haja vista já estarem em seu encalço, arremessou uma sacola plástica de cor preta que carregava. Foi

abordado e identificado como PHILLIP FERNANDES BARBOSA e, durante a revista pessoal, em seu bolso localizaram R\$ 18,00 em notas trocadas e, na sacola que ele dispensou, 28 porções de maconha, 43 porções de crack, 92 porções de cocaína e 03 frascos com um líquido incolor que aparenta ser lança-perfume. Indagado, mesmo lhe sendo relatado que foi flagrado dispensando a sacola, negou que eram suas. Diante dos fatos deram voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas a fim de garantir a integridade física da guarnição e detido bem como evitar fuga. (fls. 05). Em juízo, seu depoimento foi dispensado pelas partes (fls. 126/127).

A testemunha de acusação MAICON FREITAS CRUZ relatou na fase policial que: Durante o patrulhamento na Rua Joaquim Basílio, local conhecido como ponto de venda de drogas avistaram 05 indivíduos que ao perceberem a viatura policial, saíram em desabalada carreira, fugindo sentido uma ponte de madeira. O último carregava uma sacola de cor preta nas mãos e, ao ver que não conseguiria fugir, a dispensou. Foi abordado e em seu bolso, encontrada a quantia de R\$ 18,00. Foi identificado como PHILLIP FERNANDES BARBOSA e, na sacola que ele dispensou localizaram 28 porções de maconha, 43 porções de crack, 92 porções de cocaína e 03 frascos com um líquido incolor que aparenta ser lança-perfume. Indagado, mesmo informado que foi flagrado dispensando a sacola, negou a propriedade das drogas. Diante dos fatos deram voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas a fim de garantir a integridade física da guarnição e detido bem como evitar fuga. (fls. 06). Em juízo, a testemunha de acusação afirmou que: estava de patrulhamento numa região de bar, tendo visualizado um indivíduo com sacola e empreendeu fuga ao visualizar a viatura, tendo arremessado uma sacola que ficou presa próxima à árvore; que na abordagem o réu tinha dinheiro, cerca de R\$ 20,00; que na sacola havia bastante droga como maconha, cocaína, pedra de crack; que não conhecia o réu e não se recorda de tê-lo abordado anteriormente; que o réu afirmou que a droga não era dele e que estava no local há pouco tempo e que estava segurando a sacola para um terceiro; que havia mais 2 ou 3 pessoas mas conseguiram fugir; que um deles estava antes e provavelmente era o olheiro; que o local era viela; que o momento em que a viatura entrou na viela o réu já estava com a sacola nas mãos (fls. 128/129).

Portanto, as testemunhas de acusação apresentaram um depoimento coeso na fase policial, o qual foi reafirmado judicialmente:

O testemunho dos policiais foram coesos e encontram respaldo nas demais provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido:

“Depoimentos de policiais. Presunção de idoneidade. São idôneos os depoimentos de policiais civil e militares, prestados na polícia e em Juízo, de forma coerente e em harmonia com outros elementos probatórios existentes nos autos, podendo embasar decreto condenatório” (RJTJERGS 182/132).

TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUALIFICADO

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Há de se levar em conta que os acusados e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

“O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (TJSP, RT 752/586);

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais

testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (TJSP, RT 614/275);

“Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso” . (TJMG, RT 604/407).

Como visto, os depoimentos dos agentes de segurança são claros quanto à efetiva participação do réu no crime de tráfico e nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos policiais, lembrando que pequenas divergências entre as declarações prestadas, sequer existentes na hipótese, não bastam, por si só, para infirmá-las.

Além disso, não demonstrou a Defesa, como seria de rigor, eventual motivo que teriam os policiais civis para mentir em juízo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (artigo 156, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

CONCLUSÃO

Portanto, demonstrado que o réu trazia a droga, o seu destino tem que ser analisado pelos demais elementos que cercam a questão.

No caso dos autos, a quantidade e variedade de droga apreendida (maconha, cocaína, "crack" e "lança-perfume"), a forma como estava dividida e embalada para pronta distribuição, o local dos fatos ser conhecido como ponto de tráfico, os antecedentes criminais do réu e, ainda, o depoimento das testemunhas, levam à certeza de que o réu trazia drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

Assevero não ser crível a versão do réu de que estava no local somente para comprar uma porção de maconha para seu consumo.

IRRELEVÂNCIA ATOS DE MERCANCIA

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em “possuir”, “guardar” e “trazer consigo” a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito:

A propósito: “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 – 5ª Câmara Criminal - Campinas – v.u. – j. 03.09.09 – Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542).

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

NÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 - USO

Ressalta-se que no caso dos autos, as circunstâncias que cercaram os fatos, demonstram a traficância e não autorizam a eventual classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06).

Resta, portanto, afastada a hipótese de desclassificação para o delito de uso.

Nesse sentido:

"DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09).

E o fato de, eventualmente, o acusado afirmar que é usuário de droga, e que estava no local somente para comprar maconha para seu consumo, difere do conteúdo probatório e não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, isso porque a testemunha policial, afirmou ter visto o réu carregando a sacola que continha a droga, e com a aproximação da viatura, empreendeu fuga e lançou a sacola fora, sendo a condenação de rigor no presente caso, pois caracterizada a traficância. Cita-se como reforço de fundamentação:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498).

Desse modo, bem demonstrada se encontra a responsabilidade penal do réu pelo delito apontado na inicial, sendo de rigor a sua condenação. Em suma, demonstrado que o réu trazia consigo 28 (vinte e oito) porções da droga conhecida como "maconha", com massa bruta total de aproximadamente 67g (sessenta e sete gramas); 92 (noventa e duas) porções da droga conhecida como "cocaína", com massa bruta total de aproximadamente 94g (noventa e quatro gramas); 43 (quarenta e três) porções da droga conhecida como "crack", com massa bruta total de aproximadamente 11g (onze gramas); 03 (três) frascos de substância conhecida como "Lança-perfume", com volume bruto total de aproximadamente 80ml (oitenta mililitros), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de comercialização.

Passo, pois, à dosagem da pena.

1.A) Pena-base: 5 anos de reclusão e, 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso dos autos, tratando-se de tráfico de maconha, cocaína, crack e lança-perfume, entendo por exasperar a pena-base em 1/4 (um quarto) resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e, pagamento de 625 dias-multa. A2) Conduta social,

motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu não é portador de maus antecedentes, conforme certificam os documentos de fls. 32/33 e fls. 35/36. Enunciado da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policial e ações penais em curso para agravar a pena-base"

Em se tratando de delito submetido a Lei de Drogas, o conteúdo do artigo 42 do diploma dispõe que: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes do STF: vg. HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki.

Anoto que: a Cocaína é substância entorpecente, altamente viciante que afeta o sistema neurológico e imunológico de forma irreversível, e, além de transformações internas, o uso constante causa uma degradação física evidente; no que se refere ao crack - especialistas classificam como a terceira droga mais prejudicial ao usuário, apesar de ser derivado da cocaína, o crack, pelo fato de ser consumido por meio de fumo tem seus efeitos ainda mais potentes e duram períodos mais curtos, o que gera o consumo de maiores quantidades; a heroína - é considerada como uma das drogas mais viciantes e perigosas do mundo pela OMS (Organização Mundial da Saúde) isso pelo seu alto nível de vício e dependência, ademais, diminui a frequência cardíaca o que caracteriza grande riscos de o consumidor sofrer uma overdose.

Quanto a fração a ser aumentada, é sabido que não há previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto. Desta forma: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Destaco que, respeitado posicionamento diverso, entendo que a natureza da droga deve ser considerada nessa fase inicial, autorizando-se que o réu seja beneficiado com eventual atenuante ou causa de diminuição de pena, caso incorra na hipótese. Assim, estará sendo alcançada uma justa individualização da pena, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Por outro lado, filio-me à orientação de que a quantidade de droga nos dá parâmetro para análise da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, salvo em casos em que estiver presente os maus antecedentes e/ou a reincidência que já revela a trajetória criminosa do réu.

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, uma vez que o réu praticou o delito durante a pandemia do Covid-19, em ocasião de calamidade Pública (Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020). Não obstante o requerimento do representante do Ministério Público para o afastamento da agravante, este Juízo, respeitado entendimento diverso, reconhece tratar de circunstância de caráter objetivo, devendo ser, portanto, aplicada ao presente caso. Também neste sentido: "Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as

calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4a Câmara Criminal, j. 09/03/2021).

O réu possuía 20 anos de idade na data dos fatos, conforme documento de fls. 27, por essa razão é aplicável a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Assim, nos termos do artigo 67, CP, em razão do concurso de agravante e atenuante, a menoridade relativa prepondera por ser atributo da personalidade do agente. Sendo preponderante, a menoridade tem um peso maior que o das agravantes, de modo que é incabível uma mera compensação, contudo deve ser mitigada por aquela de modo que, atenuo a pena em 1/10, resultando na pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

C) Causas de aumento e de diminuição: Por outro lado, acolho a manifestação ministerial (fls. 126/127) e deixo de considerar a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas, porquanto, o croqui do local (fls. 72/73), apontou que o lugar do crime dista cerca de 700 metros da Escola Municipal. Em que pese a lei não especificar a distância para aplicação da majorante, a distância referida não pode ser considerada compatível com o termo imediações, que tem significado de redondezas, arredores, vizinhanças ou proximidades e, no caso dos autos sequer os locais situam-se na mesma rua/avenida, ainda se exigindo uma caminhada considerável para alcançar tal distância. A par disto, a prova dos autos não demonstrou uma efetiva influência do tráfico exercido pelo agente neste local.

Não aplicável ao caso a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, pois quantidade da droga destinada ao comércio (166 porções), não autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido: “não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para negar a redução a maior na terceira etapa da dosimetria, mas apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido” (HC nº 124.898/MS, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe de 29/3/2010.)

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo que na espécie é de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

D) LIBERDADE: O acusado não faz jus ao apelo em liberdade em razão da prisão em flagrante, bem como, por ter permanecido preso durante a instrução pela decretação da sua prisão preventiva (fls. 54/56). Não faria sentido agora, com sentença condenatória, ficar solto, se a situação que motivou a sua prisão cautelar permanece inalterada (HC 867.918-3/3, 5ª Câmara Criminal, Rel. Sérgio Rui, 6-10-2005, v.u., Voto n. 4069; HC 517.60/0-00, São Paulo, 13ª Câmara Criminal, Rel. Lopes da Silva, 9-6-2005, v.u.; TJSP, RT 836/548).

E) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado aos hediondos, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime fechado, como expressamente previsto no artigo 2º, II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07. Acrescento ainda os fundamentos da dosimetria da pena.

F) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Não estão presentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

G) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não estão presentes os requisitos do artigo 77, II, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação penal e CONDENO o réu PHILLIP FERNANDES BARBOSA como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, fixando-a em reclusão de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e, pagamento de 562 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida nos termos da fundamentação.

Expeça-se mandado de prisão.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, ficando, nos termos do artigo 63 da Lei 11.340 decretada a perda da importância de R\$ **em favor da União, que deverá ser revertida diretamente ao Funad.

Libere-se certidão de honorários a favor da Defesa, na hipótese de nomeação pelo Convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil, no valor integral de tabela ou no equivalente a 70% (setenta por cento), se houver recurso.

Condeno, outrossim, o acusado ao pagamento de taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, "a", da Lei nº 11.608/03, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C.

Francisco Morato, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA